

1501069-65.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... de cocaína) e dinheiro. O réu confessou o tráfico. Não conhecia o réu anteriormente. O local é conhecido como ponto de tráfico (já fizeram várias prisões no local).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Mauro.

O fato de a testemunha ser agente de segurança não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501069-65.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501069-65.2022.8.26.0537 Controle nº 789/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN LIMA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

JONATHAN LIMA MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 do Código Penal, porque no dia 19 de maio de 2022, por volta das 10:00 horas, na Passagem Monte Alegre, altura do n.º 140, Bairro Jardim Casa Grande, adquiriu, guardava, tinha em depósito, entregou e forneceu, para fins de entrega e consumo de terceiros, maconha e cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 34/37).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 73/75), sendo a denúncia recebida em 17.08.22 (fls. 82/83). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela v reincidência

específica, fixação de regime fechado e perda do dinheiro apreendido. A alegação de agressão é afastada pelo laudo de exame de corpo de delito negativo (fls. 43) e quanto ao pedido de dinheiro pelo policial é informação isolada nos autos.

O defensor do acusado requereu a absolvição por insuficiência de provas ou que seja internado por ser usuário, em caso de condenação a fixação da pena no mínimo legal e regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 04), o réu permaneceu calado. Em juízo, confessou que estava traficando por necessidade, para sustentar seu vício (recebia em drogas) e para ajudar a sua mãe. Tem 20 anos e trabalhava como aprendiz (ajudante de produção). Tem condenação por tráfico de 2020. O policial Elvis já fez abordagens anteriores inadequadas. Foi agredido por este policial e ainda pediu dinheiro. Foi internado por um mês para tratamento das drogas. É viciado em drogas desde 15 anos de idade. Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que atuavam em operação de combate ao tráfico, diligenciaram até o local dos fatos, efetuaram breve campanha e observaram que o réu se comportava de forma suspeita. Relataram que presenciaram que alguns transeuntes se aproximavam do réu, davam dinheiro e este entregava uma porção de droga, que retirava de uma sacola plástica verde escondida em uma caixa de energia elétrica no muro, a cerca de 20 metros de onde aquele se encontrava. Narraram que em dado momento, quando o réu foi até a sacola apanhar uma porção de droga para entregar a um usuário, que aguardava ali próximo, decidiram abordá-lo. Afirmaram que ao se aproximarem o réu tentou se evadir, mas conseguiram detê-lo mediante uso de força moderada. Narraram que o réu confessou que estava traficando, não falou para quem trabalhava e disse apenas que ganharia uma porcentagem do que vendesse no dia. Falaram que dentro da sacola plástica apreendida encontraram R\$ 232,00, 2 porções de cocaína e 11 porções de maconha.

Elvis (policial), em juízo, afirmou que estavam em operação, viram o réu atendendo o usuário, o qual se deslocava uns 20 metros, pegava droga na caixa e entregava. Viram isso umas duas vezes, quando o réu pegou a droga na caixa de luz (com porta onde fica o relógio), o mesmo tentou correr, mas o abordaram. Não conseguiram pegar o usuário. Na sacola havia drogas (11 maconha e 2 de cocaína) e dinheiro. O réu confessou o tráfico. Não conhecia o réu anteriormente. O local é conhecido como ponto de tráfico (já fizeram várias prisões no local).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Mauro.

O fato de a testemunha ser agente de segurança não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

“PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levemente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação” (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 09 - 02 invólucros de cocaína e 11 porções de maconha) e diversidade (cocaína e maconha), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro, não sendo provada a sua procedência, as confissões informal e judicial e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

“Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização” (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

“Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio” (RJTJSP 97/492).

No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (09 - 02 invólucros de cocaína e 11 porções de maconha) demonstram que se destinava ao tráfico. Ademais, sequer provou ser usuário, pelo que também não é caso de internação para tratamento.

Quanto à alegação do réu de que foi agredido é afastada pelo laudo de exame de corpo de delito que não constatou lesões (fls. 43). Em relação à alegação do réu de que o policial pediu dinheiro está isolada nos autos.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 11/13) e laudo definitivo (fls. 91/93).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 29 - proc. 1500556-68.2020).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

"Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos e 500 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado.

Compenso a reincidência e a menoridade do réu, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.ª Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.ª ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito a decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º

1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário).

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente específico (09 - 02 invólucros de cocaína e 11 porções de maconha), demonstrando que não foi um fato isolado em sua vida. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis" diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 19.05.22 pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 18.05.24).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência específica (circunstância judicial agravante) não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO JONATHAN LIMA MARTINS à pena de 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei 8072/90, que o M.P não concordou com o recurso em liberdade, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), inclusive conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, recomenda-se na prisão em que se encontra. Fls. 75: Concedo os benefícios da Justiça Gratuita, diante da situação econômica do réu (não provou possuir ocupação lícita). Coloque-se a tarja indicativa. Sem custas

(Lei n.º 11.608/03) por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 09 e 49/50) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União (art. 63 da Lei n.º 11343/06), providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à sacola plástica apreendida (fls. 09), já periciada (fls. 94/96), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 39), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06) e o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 14 de setembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA